

1500654-65.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... da cadeia nunca mais mexeu com nada de crime, de tráfico. Seu único problema era usar drogas. Tinha levado o carro para consertar e foi comprar a droga para usar e ia voltar para casa. Deixou a chave no contato.

A ré, Daiane Lunara Elizei, em sede de autodefesa disse que já foi presa por tráfico no SBT mesmo. Tem 29 anos. Mora com seus pais e a agora está morando com um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500654-65.2022.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500654-65.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2251276/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 27417926 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2251276 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE LUNARA ELIZEI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Daiane Lunara Elizei e João Paulo Pires Aranha, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 11h30,

no local denominado "Biqueira do SBT", localizado na Rua João Quessada, Nova Espera, nesta cidade e comarca, agindo com conluio e previamente ajustados entre eles, para fins de comércio, guardavam, tinham em depósito e traziam com eles, 18 eppendorff's contendo cocaína, pesando cerca de 19,92g, 16 pedras de crack, com peso aproximado de 4,44g, e 13 invólucros de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 21,75g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de págs. 103/105 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/101.

O réu João Paulo Pires Aranha foi devidamente citado (pág. 138) e apresentou defesa prévia (pág. 135). Aduziu, em síntese, que inexistem preliminares a serem arguidas, do mesmo modo que inexistem documentos a serem juntados. A defesa reservou-se o direito de se manifestar em sede de alegações finais, quando pleitearia a absolvição do acusado. Apresentou rol de testemunha.

A denúncia foi recebida aos 19 de outubro de 2022. Na ocasião designou-se data para audiência de instrução, debates e julgamentos. Ainda na oportunidade, restou determinado o desmembramento da ação penal, tramitando a ação com relação ao denunciado João Paulo, preso.

Manifestou-se a defesa do réu João Paulo, alegando ser imprescindível a oitiva da corré para o deslinde feito, posto que, com o desmembramento do feito e a ausência de tal oitiva, haveria prejuízo ao acusado, na medida em que a corré, que por óbvio estava presente na ação dos policiais, poderá esclarecer o que realmente aconteceu.

A ré Daiane Lunara Elizei foi citada às págs. 168, e apresentou defesa prévia às págs. 170/172, aduzindo, quanto ao mérito, que reserva-se no direito de provar sua inocência em sede de alegações finais.

Conforme despacho de págs. 173, tornou-se sem efeito a decisão que determinou o desmembramento do processo com relação a ré.

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ e disponível aos interessados (pgs. 202/204).

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido.

Em memoriais, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a procedência da ação penal. Elaborou exposição da prova oral coligida e concluiu que a narrativa dos réus e da testemunha de defesa é repleta de contradições, diferentemente do depoimento dos policiais. Considerando a variedade de drogas requer o aumento da pena base, destacando a reincidência de João Paulo. Daiane, no entanto, pode ser beneficiada com o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Requer o regime fechado para João Paulo e aberto para Daiane - pgs. 209/215.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se em prol de João Paulo Pires Aranha nas pgs. 218/225. Alega que as únicas testemunhas são os próprios policiais, restando contaminada a prova diante da atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Alega que o depoimento dos policiais deve ter o mesmo valor do depoimento dos réus e que os policiais deveriam ter gravado a atuação. Destaca a negativa de João Paulo e a versão de Daiane, também refutando a traficância. Invoca o benefício da dúvida

para que seja absolvido o réu ou desclassificada a imputação para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas.

Memoriais da ré Daiane Lunara Elizei nas pgs. 233/238 requerendo a absolvição da ré, diante da negativa externada no interrogatório. Invoca o benefício da dúvida reputando insuficiente a prova coligida para a imposição de qualquer condenação. Pugna, alternativamente, pela desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas. No que tange à dosimetria, também requer a observância do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-se o regime inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão em flagrante (págs. 32), requisição de IC (pág. 35), além do auto de constatação preliminar a págs. 34, fotografia de págs. 33, depósito do valor apreendido - pgs. 95.

Posteriormente vieram à lume os laudo químico-toxicológico de pgs. 97/99 - 3,4 gramas de cocaína e 18,4 gramas de maconha - massas líquidas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Welther Vaz Martins, policial civil, informa que o ponto de drogas é monitorado há mais de ano e um dia antes da prisão, receberam denúncia de que a ré e seu companheiro, que tinham sido presos no mesmo local, dias antes, estavam ali traficando novamente. Constataram movimentação típica de tráfico de drogas e havia um usuário, magro, alto. O usuário se aproximava da ré e ela serviu umas duas ou três vezes e o João Paulo uma vez. Eles recebiam algo, iam até o arbusto, retiravam algo e entregavam para o usuário. Daiane tinha 2 porções e João não tinha nada consigo, mas no local onde eles mexiam havia as drogas apreendidas. A denúncia mencionava explicitamente o nome "Daiane". O depoente não conhecia a ré. João disse que não estava traficando e sim a Daiane, imputando a traficância exclusivamente a ela. Mas, esclarece que viu o réu entregando droga uma vez. A pochete estava entre eles e ambos mexiam na pochete. A denúncia, ou melhor, informação, chegou um dia antes e fizeram a diligência no outro dia de manhã. Ficaram lá não mais do que uma hora. A denúncia não citou o nome de João Paulo.

César Augusto Seridônio relata que no dia antes dos fatos receberam delação anônima de que a ré e outro rapaz estavam traficando na biqueira do SBT que já era conhecida. A denúncia inclusive dizia que a ré já tinha sido presa ali e libertada numa audiência de custódia. Ela serviu ali, duas ou três vezes. Ele também serviu uma vez, uma pessoa a pé. Resolveram abordar o casal. A ré tinha 2 porções de crack para venda e na pochete, que estava no pé de uma moita onde eles abaixaram, encontraram mais drogas e dinheiro. Não conhecia nenhum deles e eles não apresentaram nenhuma justificativa. Deu para perceber bem eles pegando a droga ali e entregando. Ficaram por ali por 50 minutos, quase uma hora. Não havia nada com João Paulo. Não abordaram usuários porque estavam apenas numa equipe mais próxima e a outra equipe estava a distância e não foi possível abordar usuários. João Paulo

foi em direção à pochete uma vez, pegou algo e depois retornou e mexeu na pochete de novo.

Francisco de Assis Alves não viu a operação. Não sabe se ele tem relação com a Daiane. Conhece o réu porque faz serviços para ele e já viu ele usando maconha. Não sabe o que ele trabalha, acha que era serralheria. Não sabe de mais nada. Não sabe o nome da mulher dele, mas não sabe o nome. Quem lhe avisou da prisão dele foi uma pessoa porque o carro dele estava aberto na rua debaixo. Pegou o carro e levou para cima. Soube que ele foi preso na parte da tarde. Não se lembra o horário certo. A borracharia fica próximo a essa biqueira do SBT.

O réu, João Paulo Pires Aranha em oportunidade de autodefesa disse que tem 36 anos. Foi preso em 2018 por tráfico de drogas. Saiu da cadeia em agosto de 2019. Mora com sua esposa e filha. Trabalha com gesso atualmente. Sua esposa é a Jaqueline. Não tem relação com a ré. Faz uso de crack e maconha. Nunca foi internado. Era moderado, usava em casa. Ouviu o que os policiais disseram e entendeu. Não colocou a mão em pochete. Apenas entregou um cigarro para uma pessoa. Não mexeu em moita nenhuma. Foi um cigarro normal. Era um usuário. Viu quando eles abordaram a Daiane e não esboçou reação. Tinha apenas um cachimbo consigo. Era só o que tinha. Havia um maço de cigarro também. Viu que a polícia encontrou a droga próximo de onde ela estava sentada. Eles falaram que viram ela dispensando e não falaram nada para o depoente. Foi ali apenas pegar para usar. Fazia uns 20 minutos que estava ali. Ficou conversando, chegou um rapaz ali e nesse intervalo ocorreu tudo isso. Uns 20 minutos, no máximo. Comprou crack e fumou ali mesmo. Nunca foi abordado por esses policiais e não tem problema com eles. Depois que saiu da cadeia nunca mais mexeu com nada de crime, de tráfico. Seu único problema era usar drogas. Tinha levado o carro para consertar e foi comprar a droga para usar e ia voltar para casa. Deixou a chave no contato.

A ré, Daiane Lunara Elizei, em sede de autodefesa disse que já foi presa por tráfico no SBT mesmo. Tem 29 anos. Mora com seus pais e a agora está morando com um amigo. Tem 3 filhos. Estudou até o terceiro colegial. Está desempregada, começou a catar reciclagem. Conhece o João Paulo de perto da casa dele. Mora duas ruas para trás da casa dele. Ouviu o que os policiais disseram. Estava segurando a droga apenas, não serviu ninguém. O João chegou lá também para comprar e ficou lá esperando. Nisso a polícia chegou. Não fazia cinco minutos que o João estava lá. A pochete era de uma menina que deixou na confiança da depoente. Ela ia dar mais um papel para a depoente. Sempre fazia isso para ela mesmo. João Paulo não mexeu na pochete, nem serviu ninguém. Na pochete estava o maço de cigarro da depoente. Ele pediu cigarro para a depoente assim que chegou lá. A depoente tinha colocado o cigarro dentro da pochete. Quando João Paulo chegou a moça não estava lá, tinha saído a uns 10 minutos. Ele falou: "cadê, não tem ninguém aí". Aí a polícia chegou. O dinheiro que estava lá não era da depoente. Tinha apenas R\$ 20,00, mas já tinha gasto comprado crack. Era os 2 papéis que tinha acabado de comprar e estavam no seu soutien. Nunca tinha sido abordada por esses policiais antes. João não estava lá vendendo. Ele só foi até a pochete pegar o cigarro lá. A depoente é usuária de drogas há 9 anos. Foi internado uma vez só, ficou limpa 4 anos e recaiu. Não costumava ir na biqueira em questão. Foi uma das primeiras vezes que foi lá. A pessoa que deixou a pochete lá sabe que mora lá para baixo, sempre pegava com ela e com o marido dela. Tinha feito uso de droga no dia dos fatos.

2 -) DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA E DIREITO APLICÁVEL.

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a proclamar: “Não compromete a credibilidade da palavra dos policiais eventual violência contra os presos ou variação sobre pormenores a respeito do fato criminoso.” (TJSP, Ap. 203.471-3/0, 5.^a Câ. J. 26.9.1996, rel. Des. Dante Busana, RT 737/602).

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho e denúncia caluniosa.

Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento discriminatório em violação do princípio da igualdade e temor de enfrentar o fato e o seu valor correspondente, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1.^a Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19.^a Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório,

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que em se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

No que se refere à validade da denúncia anônima, apesar de sua precariedade, ela deve ser objeto de investigação policial, em face da possibilidade de serem apurados elementos suficientes ao oferecimento de denúncia ou representação em caso de infratores.

Considerando a enorme incerteza em torno de suas informações, recomenda-se especial cautela no procedimento, visando preservar o acusado de desnecessário constrangimento.

Mesmo que a Constituição vede o anonimato na manifestação do pensamento (art. 5º, IV), não há falar em rejeitar-se, de plano, comunicação de delito com procedência desconhecida, porque se poderia estar coartando a pretensão punitiva do Estado em circunstância própria ao desenvolvimento de ação penal ou procedimento para apuração de ato infracional.

A jurisprudência tem cancelado a denúncia anônima como instrumento hábil a desencadear a persecutio criminis. O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais apresenta escólio singular:

“A denúncia anônima não é ato ilícito, sendo incapaz de viciar a investigação criminal, encontrando amplo fundamento constitucional, por visar a preservação da ordem pública e garantir, paralelamente, a incolumidade dos denunciante, ambos objetivos fundamentais de todo o sistema da segurança pública previsto na Constituição Federal (art. 144, caput). (Apelação Criminal nº 1.0024.07.765340-0/001(1), 5ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Adilson Lamounier. j. 02.09.2008, maioria, Publ. 15.09.2008).”

Em obra dedicada ao tema “A busca da verdade no processo penal” Marco Antônio de Barros conclui:

“Existem dois entendimentos sustentados na literatura jurídica. Uma corrente entende que o anonimato não se mantém ao ser confrontado com a norma constitucional. E a outra corrente justifica a sua validade, argumentando que o anonimato dá ensejo a uma investigação preliminar, sendo que eventual indiciamento e acusação posterior sempre ficarão condicionados ao arrimo de provas colhidas no curso das investigações. Desde que a investigação policial provocada pelo disque-denúncia seja efetivamente desenvolvida com esteio absolutamente regular, entendemos que não há parâmetro legal para impugnar as provas pertinentes à ocorrência de ilícito penal originariamente noticiado à Polícia Judiciária por este modo.”

O que seria inadmissível é a condenação dos denunciados apenas com base na delação não-identificada, ou seja, na hipótese de nada mais existir estaria vedado ao

Estado-Juiz fiar-se apenas na notícia anônima para cancelar condenação.

No entanto, nada impede que haja atuação policial desencadeada a partir de informação não-identificada. E, no presente caso, a atuação policial conseguiu reunir prova da materialidade de crime contra a saúde pública e identificou a autoria de forma evidente, pois os réus foram visualizados no local entregando drogas para usuários e na sequência houve efetivamente apreensão de drogas e dinheiro cuja origem não está comprovada.

Saliente-se que ambos os policiais civis empenhados na diligência são oriundos da DIG de Casa Branca. Assim, não fosse pela real existência da denúncia anônima não há explicações outras hábeis a esclarecer como ambos vieram para São José do Rio Pardo e conseguiram não apenas chegar ao local exato onde Daiane (alvo da denúncia) estava como também efetuar a prisão.

A testemunha de defesa nada presenciou. No entanto, coloca o réu no local do crime, pois ele teria deixado o veículo naquelas imediações, segundo a testemunha.

O próprio réu não nega que de fato estava ali e chegou até mesmo a ver a corréu sendo abordada.

Labora em equívoco a defesa ao alegar que a versão condenatória esteia-se tão-somente no depoimento dos policiais. Não se pode desconsiderar que houve, de fato, apreensão de drogas diversas e fracionadas naquela localidade, conhecido ponto de venda de drogas no qual houve a diligência investigatória diante de denúncia de que a ré agia, vendendo drogas, juntamente com um comparsa. Portanto, além da versão dos policiais há prova da materialidade e a própria denúncia precedente.

A denúncia anônima foi confirmada com a apreensão dos entorpecentes e todo o cenário narrado pelos policiais que descreveram típico enredo de mercancia de entorpecentes.

A versão dos réus está sendo valorada, assim como as demais provas anteriormente referidas.

Daiane, como visto, confessa que estava na posse das drogas, guardando-as para terceira pessoa. No entanto, não apresentou contraprovas a respeito da alegação das duas testemunhas policiais no sentido de que ela não apenas tinha a posse das drogas, como também entregava para usuários.

Vale lembrar que a mera posse para entrega ao consumo de terceiros também bastaria para tipificação da conduta nos moldes do art. 33 da Lei de Drogas.

A versão de João Paulo, por sua vez, não se sustenta. Não houve apreensão de qualquer cachimbo e a pessoa que ele diz que deu um cigarro não foi arrolada como testemunha. Não passa despercebido que Daiane é quem disse ter dado um cigarro para João Paulo, o que evidencia a desarmonia entre as versões dos réus.

Assim, a negativa dos réus não deve impressionar, pois eles não estão obrigados a fazer prova contra si mesmos (*Nemo tenetur se detegere*) e a tentativa de furtar-se às consequências penais é o normal e esperado na grande maioria das ações criminais.

Em atenção ao argumento defensivo de que os réus merecem ser beneficiados pela dúvida, tem-se que a dúvida capaz de favorecê-los deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de hipóteses antagônicas àquelas que ressaem da prova dos autos, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o

"decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (MALATESTA, Nicola Flamarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 145-146 - destaques do Juízo).

Como visto, as provas amealhadas pelo Ministério Público convergem no sentido de sustentar a tese vertida na denúncia, ao passo que os réus não lograram apresentar versão diversa igualmente consistente capaz de lançar dúvida razoável sobre o contido na presente ação penal em seu desfavor.

Diante do panorama probatório, conclui-se que a conduta praticada pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal esculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Nova Lei de Drogas), consideradas as circunstâncias que permearam a apreensão dos entorpecentes.

É de se ressaltar que as normas incriminadoras (artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006) encerram uma potencialidade abrangente de duas condutas, dependendo da conduta do réu a justa e exata caracterização, como usuário ou traficante, exigindo, para o reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, prova a ser produzida pela defesa de que a substância entorpecente não se destinava ao comércio ilícito.

Está desgastada a tese de tentativa dos policiais incriminarem injustamente cidadãos comuns, lançada ao léu por muitos e muitos réus, que tentam subverter os policiais em criminosos que pretendem encarcerar cidadãos inocentes, como se não tivessem criminosos o bastante para se ocupar.

Destarte, não há resquício de dúvida de que todos estes fatores conjugados - depoimentos harmônicos dos policiais e prova da materialidade, evidenciam a absoluta preponderância dos elementos angariados pela acusação que logrou fazer com que o fiel da balança pendesse no sentido da pretensão punitiva.

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 103/105 para CONDENAR DAIANE LUNARA ELIZEI e JOÃO PAULO PIRES ARANHA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhes as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Quanto ao réu JOÃO PAULO PIRES ARANHA:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" é composto de duas grandezas: quantidade em termos de diversidade e quantidade em termos de massa de entorpecentes.

O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de $5,4 + 3,4 = 8,8$ gramas de cocaína e 18,4 gramas de maconha – pgs. 97/99.

No presente caso, a quantidade-massa de drogas não é superior àquelas verificadas em apreensões regulares nesta comarca. Portanto, não está autorizado o acréscimo de 1/6 pela massa de drogas.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Cocaína, crack e Maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendido com frequência diária em São José do Rio Pardo.

No que tange à diversidade, variedade das substâncias, tem-se outra medida de valoração, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo encontra campo para acréscimo na reprimenda, pois a quantidade-diversidade (no caso três – cocaína, crack e maconha) impõe acréscimo na reprimenda, pois o traficante que tem consigo diversidade de tóxicos demonstra maior periculosidade na medida em que pode atender "clientela" ou demanda mais diversificada.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, estes fixados na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa, diante da condição econômica desfavorável do réu.

Na segunda etapa, trata-se de reincidente específico, pois consta condenação por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, "caput" do Código Penal – feito nº 1500281-56.2018.8.26.0613, o qual tramitou perante este Juízo, onde foi condenado à pena de um ano e onze meses de reclusão – regime aberto. Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 09/08/2019; Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) 20/01/2020; 20/01/2020 Audiência Admonitória - Regime Aberto; 14/06/2021 Sentença de Extinção da Pena, conforme folha de antecedentes e certidões juntadas a fls. 40/44.

Agravo a pena em mais 1/6, situando-a no patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, diante da reincidência específica.

Torno em definitiva a pena supra a ser descontada em regime inicial fechado, diante da reincidência específica e mantido o caráter hediondo da conduta.

Não permito que o réu recorra em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, restando fortalecidos os indícios de autoria, diante da sentença penal condenatória após cognição exauriente. Portanto, respondendo ao processo preso, assim deve permanecer após a confirmação de sua culpa em veredito obtido após o devido processo legal, ainda que sujeito a recurso.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra, pois o título de sua prisão cautelar passa doravante a ser a presente sentença penal condenatória recorrível.

Quanto a ré DAIANE LUNARA ELIZEI:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas reporto-me aos fundamentos expostos em relação ao corréu para majorar a pena base também em 1/6.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6 acima do mínimo legal, a saber, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Como a ré confessou que guardava a droga (ainda que para terceira pessoa), deve ser beneficiada com a atenuante respectiva, segundo súmula 545 do E. STJ. Reconduzo a pena ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

A ré faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à míngua de anotações capazes de configurar maus antecedentes ou reincidência, conforme certidão de pgs. 45/47.

Ressalvado o entendimento deste Juízo, incide ao caso o tema 1.139 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

O regime legal cabível é o ABERTO, diante da primariedade e quantum da pena imposta, afastado o caráter hediondo da conduta.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 – SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 – SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que “se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa – e com maior razão.”

Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários, notadamente no caso da ré que está respondendo a outro processo também por tráfico.

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

A cobrança fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

1 - Expeça-se guia de execução definitiva para o réu João Paulo e mandado de prisão para a ré Daiane, observando-se em relação a esta os termos do art. 23 da Resolução CNJ 417/21, com a redação atribuída pela Resolução CNJ 474/2022, “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a

pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56". A ré deverá apresentar-se em Juízo no horário das 13:00 às 16:30, ocasião em que sua audiência será "encaixada" na pauta regular. Prazo – 5 dias após o trânsito em julgado. Mantendo-se inerte, expeça-se o mandado de prisão no regime fixado.

2 - Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

3 - Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

4 - Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

5 - Se patrocinado por advogado(a) dativo(a) arbitre os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.

6 - DECRETO o perdimento do dinheiro apreendido, pois à míngua de comprovação de sua origem lícita e diante dos fatos elementos comprobatórios de traficância, conclui-se tratar-se de proveito do tráfico desempenhado em coautoria pelos réus.

7 - Caso ainda não providenciada, proceda-se à incineração das drogas apreendidas, na forma do art. 524-B das NSCGJ. Devidamente periciadas as drogas, desnecessária a amostra para contraprova.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA